Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Processo: 0828068-79.2021.8.12.0001
Autos: Procedimento Comum Cível
Autor: Jose Cicero de Oliveira
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos, etc.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada* proposta por **José Cícero de Oliveira** contra **Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**, partes devidamente qualificadas nos autos.

Afirma o requerente que é beneficiário do plano de saúde junto a requerida, possuindo a carteira de beneficiário n. 00513007018000025 e que foi diagnosticado com neoplasia maligna de laringe (câncer na laringe) em janeiro de 2019, sendo que desde então, iniciou tratamento para que pudesse curar a doença.

Relata que no mês de fevereiro de 2021, o médico que acompanha seu caso, prescreveu o medicamento Erbitux, registrado na Anvisa sob n. 100890335, para tratamento da doença e, diante disso, foi solicitado o fornecimento do referido fármaco junto ao plano de saúde requerido, o que foi autorizado, vindo a ré fornecer até o mês de julho de 2021.

Aduz que durante o tratamento com o medicamento receitado pelo médico, verificou a eficácia do fármaco, no entanto, para surpresa do requerente, ao solicitar a continuidade do tratamento medicamentoso, a ré se negou a fornece-lo, sob a justificativa de que surgiram novas lesões no exame de PET realizado pelo autor, demonstrando que referido tratamento estaria perdendo seu benefício terapêutico, o qual contraria o laudo feito pelo médico do autor que indica que o remédio Erbitux estaria trazendo melhoras em seu quadro clínico e que a continuidade deste era imprescindível, sob pena de perder toda evolução conquistada pelo paciente.

Sustenta que não há justificativa plausível para negativa da requerida em fornecer o medicamento, e que isso coloca em risco a vida do requerente, pois a moléstia que lhe acomete é grave, sendo que qualquer interrupção no tratamento pode acarretar em seu óbito.

Por tais motivos, requer a concessão da justiça gratuita e o deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré proceda o imediato fornecimento do medicamento Erbitux, em conformidade com a indicação médica, sob pena de multa para o caso de descumprimento. Ao final, a procedência do pedido para o fim de confirmar a tutela deferida, condenando a ré em obrigação de fazer, consistente na entrega do fármaco prescrito pelo médico e a condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00. Juntou documentos de f. 14-75.

Decisão de f. 78-83, em que deferiu ao autor a inversão do ônus da prova, as benesses da justiça gratuita e a tutela de urgência na forma pretendida. Determinou a citação da ré para comparecer à audiência de conciliação designada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

Contestação da ré às f. 134-158. Alega, no mérito, que a cobertura mínima obrigatória de procedimentos e eventos em saúde deve ser garantida pela operadora do plano de saúde, sem esquecer da segmentação do plano contratado pelo consumidor, e que a nova solicitação para o medicamento pelo requerente foi recepcionada em 30/07/2021, sendo que após análise da documentação apresentada, a auditoria médica e os consultores oncológicos da requerida discordaram do medicamento solicitado, pois em análise técnica, o médico desempatador esclareceu que houve perda do benefício terapêutico do tratamento com o medicamento Erbitux e, assim, não há ilegalidade na negativa de fornecimento do referido fármaco. Defende a inexistência do direito do autor, pois seu caso não configura urgência ou emergência e que a negativa ofertada pelo plano de saúde não implicou em risco iminente de vida ou de lesões irreparáveis ao autor e por isso agiu na estrita legalidade. Por tais motivos, requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos de f. 159-290.

Audiência de conciliação realizada, porém, sem acordo entre as partes (f. 291-292).

Impugnação à contestação de f. 296-302.

Cópia da decisão proferida em Agravo de Instrumento às f. 304-318, cujo recurso interposto pelo réu não foi provido, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência em prol da parte autora.

As partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendem produzir (f. 319), tendo a ré postulado pela prova pericial, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do autor (f. 323-325).

À f. 326-328, foi informado o falecimento do requerente, pugnando pela substituição do polo ativo pela inventariante, filha do falecido, Gabrielle Rodrigues de Oliveira. No mesmo ato, formulou pedido de desistência da ação em relação ao pedido de obrigação de fazer pela perda do objeto, e o prosseguimento do feito com relação ao pleito de indenização por danos morais. Indicou não ter outras provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide. Juntou certidão de óbito de f. 329, termo de inventariante de f. 330 e documentos pessoais de f. 331-332.

Despacho de f. 333 em que determinou que a inventariante regularizasse sua representação processual, com a juntada de procuração, o que foi feito à f. 326. No mesmo ato, determinou-se a intimação da requerida para manifestar concordância com o pedido de desistência com relação a obrigação de fazer.

Em manifestação de f. 338-340, a ré discordou com a desistência do pedido de obrigação de fazer, requerendo análise do mérito sobre esta questão e o prosseguimento do feito com a produção das provas requeridas.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

proposta por **José Cícero de Oliveira** contra **Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**, partes devidamente qualificadas nos autos.

1 – Perda superveniente do objeto da ação de obrigação de fazer

À f. 326-328, foi informado o falecimento do requerente, pugnando pela substituição do polo ativo pela inventariante, filha do falecido, Gabrielle Rodrigues de Oliveira. No mesmo ato, formulou pedido de desistência da ação em relação ao pedido de obrigação de fazer pela perda do objeto, e o prosseguimento do feito com relação ao pleito de indenização por danos morais.

Por sua vez, a requerida, à f. 338-340, discordou de tal pleito, alegando que a suspensão do medicamento pleiteado não acarreta a perda superveniente do objeto do pedido, uma vez que o fármaco *Erbitux* foi concedido em razão do deferimento da tutela antecipada há necessidade da análise do mérito a fim de se verificar a controvérsia estabelecida.

Isso porque, não há falar em perda superveniente do interesse de agir pelo fato da médica que atende a paciente ter determinado a suspensão do uso do fármaco ora pleiteado (f.233), haja vista que o fornecimento de medicamento ocorreu por força de decisão judicial em sede de tutela de urgência, portanto, de natureza precária, não ensejando a perda do objeto. Ademais, o interesse decorre da recusa ao fornecimento do medicamento, sendo que os reflexos patrimoniais da cobertura, ou não, permanecem mesmo após a interrupção do tratamento, referindo-se ao período cuja cobertura foi concedida, em sede de tutela provisória.

Deste modo, ante a discordância do pedido de desistência feito pela requerida, com relação a obrigação de fazer, conforme manifestação de f. 338-340, **indefiro** o pedido da autora formulado à f. 326-328, de extinção sem julgamento de mérito com relação ao pedido inicial de obrigação de fazer, devendo a presente demanda prosseguir até decisão de mérito com relação a ambos pedidos formulados na inicial (obrigação de fazer até o óbito do requerente e indenização por danos morais).

2 – Substituição processual

Como visto, o autor José Cícero de Oliveira veio a óbito na data de 23/12/2021, conforme certidão de f. 329, tendo sua filha, Gabrielle Rodrigues de Oliveira, juntado termo de inventariante de f. 330.

Assim, nos termos do artigo 75, VII, do CPC, que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, determino a alteração do polo ativo destes autos, para o fim de constar como parte autora o **Espólio de José Cícero de Oliveira**, representado por sua inventariante, **Gabrielle Rodrigues de Oliveira,** devidamente representada por seu advogado constituído à f. 337.

Às providências.

3 – Julgamento antecipado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

As partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendem produzir (f. 319), tendo a ré postulado pela prova pericial, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do autor (f. 323-325). Já a parte autora, às f. 326-328, indicou não ter outras provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Como é cediço, o juiz é o destinatário das provas, sendo que cabe a ele indeferir aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, do CPC.

É certo, ainda, que às partes é garantida produção de provas e ampla defesa, no entanto, deve ser coibida a prática de atos processuais desnecessários à luz dos princípios da celeridade e economia processuais. Acrescento que, mesmo com a entrada em vigor do novo CPC, permanece hígido o entendimento jurisprudencial no sentido de que o juízo é o destinatário da prova, estando autorizado a indeferir a produção segundo livre convencimento motivado.

Desta feita, se o processo se encontra apto a ser julgado e o magistrado entender ser desnecessária a produção de provas, a prolação da sentença é medida que se impõe, à vista dos princípios da economia e celeridade processual.

Esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

> "DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. LIMPEZA URBANA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. **1. O STJ possui entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.** 2. Assim, quanto aos arts. 131, 330, I, 458, II, do CPC, o Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que, no caso concreto, o cerceamento da participação da Municipalidade nos autos não autorizava o prosseguimento do feito e o julgamento antecipado da lide. 3. Para uma análise em sentido contrário, que leve à modificação do julgado, revela-se indispensável a reapreciação do conjunto probatório existente no processo, o que é vedado em Recurso Especial, em virtude do preceituado na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido" (AgInt no AREsp 859.429/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/09/2016).

No caso, desnecessário se torna a prova pericial, a qual teria de ser realizada de forma indireta, já que o autor da demanda veio a óbito, ou a prova testemunhal, sendo que as provas documentais produzidas nos autos até então são satisfatórias para um

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

juízo de mérito acerca da questão posta em debate.

De fato, como os documentos juntados aos autos não deixam margem à dúvidas, demonstrando inclusive as questões que cada parte pretendia demonstrar, evidente a desnecessidade da dilação probatória, não havendo se falar em eventual nulidade por cerceamento de defesa.

Assim, **indefiro** a produção de provas requerida pela parte ré à f. 323-325 e, com fulcro no artigo 355, I, do CPC, passo ao julgamento de mérito.

3 – Obrigação de Fazer

No mérito propriamente dito, a questão posta cinge-se em saber se o plano de saúde ofertado pela requerida deveria ou não fornecer o medicamento Erbitux ao autor enquanto estava em tratamento da doença que lhe acometia (câncer na laringe), cuja doença, inclusive, foi o motivo de seu óbito durante a tramitação do feito, conforme certidão de óbito (f. 129).

Prefacialmente, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que se aplicam as normas de relação consumerista previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) às obrigações contraídas com operadoras de planos de saúde comerciais, incluindo-se nessas as cooperativas, em razão das características dessas pessoas jurídicas e dos contratos entabulados.

Prescreve a Súmula 608 do STJ que: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*."

A Unimed Campo Grande é cooperativa (f. 19-72), submetendo-se ao CDC. Ademais, o art. 423 do Código Civil prescreve que: "*Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente*".

Deste modo, deve-se adotar interpretação mais favorável ao usuário do plano de saúde, não se mostrando lícita a recusa do plano de saúde em prestar o tratamento prescrito por médico especializado.

Nesse sentido:

> DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA À COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. MEDICAMENTO IMPORTADO E/OU TRATAMENTO DOMICILIAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA ABUSIVA. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 11.03.2014. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

> CPC/73. 2. Cinge-se a controvérsia a definir sobre a abusividade de cláusula contratual de plano de saúde que restringe o fornecimento de medicamento importado e de uso domiciliar. 3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente e dos dispositivos legais indicados como violados, apesar da interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. **5. O STJ possui entendimento no sentido de que é irrelevante a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei 9.656/98, uma vez que as cláusulas contratuais dos planos de saúde devem ser analisadas de acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme determina a Súmula 469 do STJ. Precedentes... 7. Se o contrato de seguro de saúde prevê a cobertura do tratamento da doença crônica que acomete a recorrida, são abusivas as cláusulas contratuais que limitam seu direito ao tratamento contratado.** 8. Recurso especial conhecido parcialmente, e nessa parte desprovido. (REsp 1641135/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017)

Feitas tais observações, estabelece o art. 16, VI, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 24.08.2001, que:

> *"Art. 16 – Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:*
> *[...]*
> *VI – os eventos cobertos e excluídos."*

Conforme o teor do supracitado artigo, perfeitamente possível a cobertura e exclusão de eventos nos contratos de plano de saúde, desde que expressos de forma clara, a fim de que o usuário possa ter prévia ciência.

Contudo, a requerida negou o medicamento solicitado sob o seguinte argumento:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Campo Grande, 13 de agosto de 2021.

DECISÃO DA JUNTA MÉDICA

Sra. Jose Cicero de Oliveira,

Em continuidade ao processo de Junta Médica, estabelecido para dirimir a divergência assistencial relativa ao procedimento Terapia Oncológica – Planejamento e 1 Dia de Tratamento, código 20104294 e Terapia Oncológica por Dia Subsequente de Tratamento, código 20104308 com o medicamento Erbitux encaminhada em 30/07/2021, sob o nº 202101155621, pelo seu Médico – Dr. Amauri Ferreira de Oliveira, CRM 3931-MS, para o qual a Unimed Campo Grande entendeu que após a análise do caso, o Dr. André Varella Katz CRM-SP 64025, que atuou como desempatador, emitiu parecer desfavorável à solicitação em análise. Em seu parecer, dr. André considerou que o surgimento de lesões novas em exame de PET/CT realizado em julho de 2021, demonstre sinais de que o tratamento em curso estaria perdendo o seu benefício terapêutico. Não se sustentando, portanto, mantê-lo.

Desta forma, informamos que a operadora não assegurará a cobertura ao medicamento Erbitux, conforme solicitação médica. Todo o processo de análise, já se encontra disponível com o seu médico (ou equipe médica) assistente.

Para maiores esclarecimentos, sugerimos que entre em contato com o seu Médico ou com a Operadora através do e-mail (oncologia@unimedcg.coop.br).

Atenciosamente.

Dr. Mateus Bringel O. Duarte
CRM-MS 11.402
Médico Auditor – UNIMED Campo Grande

Não obstante a fundamentação do plano de saúde, a negativa se apresenta manifestamente ilegal por afrontar o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

É certo que o rol de procedimentos e eventos em saúde elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, porém cuida-se de rol exemplificativo e sem caráter vinculativo, assim como as Resoluções Normativas da TAgência Nacional de Saúde, na medida que não esgotam as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde.

Da prescrição médica infere-se que o falecido José Cícero de Oliveira, foi diagnosticado com neoplasia de laringe com metástase e estava em tratamento com o fármaco Erbitux desde fevereiro de 2021, e que o paciente estava clinicamente bem, com ganho de peso e, contrariando o laudo da junta médica da ré, o médico do autor, à época, esclareceu que *"Entendemos tratar-se de paciente em progressão de doença oncológica após diversas ofertas terapêuticas, evoluindo com perda progressiva de KPS, que se aproxima de terminalidade".* ***O mesmo não apresenta perda de KPS, e também em nenhum momento o avaliador fez menção ao exame de RNM que se apresenta normal, portanto, sugiro manutenção de tratamento com Erbitux devido acreditar não haver progressão de doença"*** (grifo nosso - f. 73).

Sendo assim, como a indicação do tratamento adequado para as patologias dos pacientes compete ao médico que acompanha a situação clínica de seu

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

paciente, **mostra-se abusiva a cláusula que exclui o fornecimento do medicamento acima mencionado**, além de interferir no diagnóstico que só pode ser aferido pelo profissional da saúde que acompanhava o autor e não uma junta médica criada pela própria requerida.

A negativa, ademais, não atende ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, pois o usuário de plano de saúde tem a expectativa de poder utilizar o serviço contratado e ser atendido em caso de enfermidade, especialmente quando se segue recomendações médicas.

Se não bastasse, contraria a própria finalidade da assistência prestada pelas operadoras dos planos de saúde, que a luz do que dispõe o art. 35-F, da Lei nº 9.656/98 "*compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde*".

Logo, em que pese o medicamento pleiteado não constar no rol da Resolução Normativa nº 428/17 da ANS, tal fato não exime o plano de saúde em fornecê-lo, uma vez que se trata de rol mínimo de lista de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde.

Nesse sentido, o STJ e o nosso e. TJMS já se pronunciaram a respeito do tema aqui tratado:

> "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos. Conforme orientação desta Corte de Justiça, "**o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário**" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020). [...]." (AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)
>
> "RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA - NEGATIVA DE COBERTURA – INDICAÇÃO MÉDICA POR MEIO DE LAUDO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - ROL NÃO TAXATIVO - COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. [...] 2. Ficando comprovado nos autos que o procedimento postulado e indicado pelo médico da autora, ou seja, realização de mamoplastia redutora, não possui cunho estético, mas sim possibilita a melhora de sua saúde e qualidade de vida, já que apresenta dores pelo peso das mamas, deve ser fornecido o tratamento pretendido, mesmo que não tenha previsão de cobertura para tal e não esteja elencado no rol da ANS. 3- Tal se dá porque a ausência de previsão do procedimento no rol elaborado pela ANS não torna, por si só, legítima a negativa de cobertura, porquanto o rol de procedimentos publicado pela ANS constitui-se apenas em uma referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde, elencando os procedimentos mínimos que devem ser disponibilizados aos beneficiários. **4- O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, porém não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a cura ou melhora do quadro de saúde.** [...]." (TJMS. Apelação Cível n. 0827801-83.2016.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 29/11/2020, p: 01/12/2020).

Se não bastasse, **recentemente foi publicada a Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022**, que assentou não ser taxativo o rol procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). *In verbis*:

"Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: ....."
"Art. 10. ....
§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.
.....
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, ***constitui a referência básica*** *para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, ***a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que****:*
I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação".

Assim, considerando que o medicamento pleiteado é aprovado pela ANVISA e a prescrição médica do fármaco Erbitux estava pautado na melhora do quadro clínico do autor, conforme laudo médico de f. 73, o qual comprovava sua eficácia para o tratamento do autor à época, o fato de não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde.

Por consequência, é de rigor a procedência do pedido de obrigação de fazer.

4 - Da responsabilidade pelo prejuízo decorrente da efetivação da tutela de urgência

Pretende, ademais, o plano de saúde réu o ressarcimento dos valores gastos com a concessão do medicamento Erbitux.

Reza o art. 302 do CPC que:

"Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:
I – a sentença lhe for desfavorável;
II – obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;
III – ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

IV – o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível".

Acerca do tema, o STJ possui o seguinte entendimento:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA DEMANDA APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELA PARTE RÉ PLEITEANDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO NESSE SENTIDO. OBRIGAÇÃO EX LEGE. INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER LIQUIDADA NOS PRÓPRIOS AUTOS. ARTS. 302, CAPUT, INCISO III E PARÁGRAFO ÚNICO, E 309, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A questão jurídica discutida consiste em definir se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela antecipada, posteriormente revogada em virtude de sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por haver a autora desistido da ação. 2. O Código de Processo Civil de 2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável; ii) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (CPC/2015, art. 302, caput e incisos I a IV). **3. Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que "a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível", dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.** 4. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual. 5. Recurso especial provido."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

(REsp n. 1.770.124/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.) – destaquei

Como se vê, a obrigação de indenizar a parte contrária pelos prejuízos oriundos do deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução do mérito.

Entretanto, a hipótese em apreço não comporta ressarcimento, na medida que a tutela provisória de urgência **não foi revogada**, pelo contrário, está sendo confirmada em sentença de procedência de mérito do pedido de obrigação de fazer.

Ademais, restou comprovada a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, que somente teve suspenso o tratamento de forma indevida pela parte ré, que através de sua junta médica, disse que o autor não precisava mais do fármaco porque seu tratamento era apenas "paliativo", o que, como dito, foi contrariado pelo médico que assistia o falecido à época, conforme demonstra o laudo de f. 73.

Por fim, no caso dos autos, não há evidência de conduta contrária à boa-fé na postura do paciente falecido ou de sua família, tanto é que, logo após a ocorrência do óbito do autor, sua herdeira tratou de comunicar o fato imediatamente ao juízo, requerendo a extinção do pleito obrigacional em razão da perda superveniente, o que demonstra a boa-fé da parte autora.

Destarte, descabida a pretensão de ressarcimento formulada pelo plano de saúde réu.

5 – Danos morais

No que tange à indenização por danos morais, como visto, para que haja o dever de reparar o dano, é necessária a configuração de três requisitos, quais sejam, a conduta do agente, o dano sofrido e o nexo de causalidade, estando estes devidamente configurados no presente caso.

Na hipótese, a omissão da operadora no fornecimento do tratamento medicamentoso com o fármaco Orbitux, prescrito por médico especialista que acompanhava o requerente à época, de forma injustificada, como acima expostos, caracteriza conduta abusiva, que interferiu de modo significativo no comportamento psicológico do beneficiário, que estava em tratamento de doença severa (câncer), com expectativa de melhora do seu quadro clínico, inclusive com ganho de peso, conforme consta do laudo médico de f. 73, se depara com a suspensão do medicamento pelo fato da requerida "concluir" que o paciente estava em progressão de doença oncológica e que se aproximava de terminalidade; ou seja, o próprio plano de saúde já havia "condenado" o requerente, fato este que, sem dúvidas alguma, causou-lhe, não só ao requerente (quando ainda estava vivo), quanto aos seus herdeiros, sentimentos de angústia e aflição que afetaram diretamente seus direitos de personalidade, gerando assim prejuízo moral, prescindindo de culpa nesse caso, por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

Trata-se de dano *in re ipsa*, decorrente da conduta ilegítima da requerida que extrapola o mero descumprimento contratual, causando prejuízos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, por infligir situação de aflição psicológica e de angústia ao requerente que lutava contra uma doença grave, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Ademais, a parte autora se viu obrigada a buscar o Poder Judiciário para obter o tratamento medicamentoso que fazia jus, sendo evidente a violação à princípios fundamentais como o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana.

Em mais de uma vez, nosso TJMS já decidiu a respeito do tema. Vejamos:

> EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA - ABUSIVIDADE- ROL DA ANS- MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – CIRURGIA REALIZADA – RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Cediço que o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como direito fundamental do homem, devendo ser garantida a dignidade e o bemestar restando incabível sobrepor interesses contratuais em detrimento da vida. De se ressaltar que as normas provenientes da ANS não possuem o condão de infirmar o acordo entre as partes, muito menos a orientação médica expressa, que visa assegurar a plena saúde do paciente. O rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo, mas, sim, exemplificativo, isto é, a lei traz a cobertura mínima obrigatória a ser respeitada pelos planos privados, o que não significa que estes estão desobrigados a custear eventuais tratamentos e/ou procedimentos que não constem naquele, na medida em que cabe ao médico e não ao plano de saúde prescrever o tratamento necessário à patologia que acomete o seu paciente. Logo, havendo prescrição do médico acerca do procedimento/tratamento a ser realizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e garantia constitucional de acesso à saúde. Portanto, independente da questão afeta à taxatividade ou exemplaridade do Rol da ANS, o procedimento/tratamento prescrito deve ser coberto pelo plano de saúde. **A situação a que foi exposto não se caracteriza como mero dissabor ou aborrecimento, pelo contrário, o tratamento delicado que necessitava aliado à negativa de uma contraprestação, ao expor a angústia e a dor que suportou, torna imperiosa a necessidade de manter o dever de indenizá-lo pelos danos morais suportados, justificando, pois, a compensação econômica, no montante arbitrado na sentença recorrida de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância razoável e hábil para atender as finalidades da reparação civil, especialmente ao caráter pedagógico de reprimenda.** (TJMS. Apelação Cível n.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

0840843-05.2016.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 27/07/2022, p: 29/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO RECURSAL – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA APELANTE – COMPLEXO UNIMED – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi oportunizado às partes a produção das provas que entenderam necessárias ao esclarecimento dos fatos, com dispensa daquelas desnecessárias para o julgamento da lide. II - Não obstante a Unimed Campo Grande aduzir que a Unimed Norte Nordeste encontra-se inadimplente, considerando a adimplência da parte autora com o plano de assistência médica firmado com esta última, deve a Unimed Campo Grande prestar-lhe a devida contraprestação pelo serviço contratado, que engloba atendimento médico e hospitalar, além da realização de exames, já que estas cooperativas médicas possuem uma rede de intercâmbio, especialmente porque o plano é de abrangência nacional. III - O Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. **IV - O direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura do plano de saúde é devido, pois o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário do plano de saúde, uma vez que, ao pedir a autorização de cobertura, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.** V - Para a quantificação da indenização a título de dano moral, deve-se ter em mente que o seu montante deve garantir à parte credora uma reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. (TJMS. Apelação Cível n. 0809135-92.2020.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 21/03/2022, p: 23/03/2022)".

Assim, com a negativa de cobertura de tratamento médico, o dano moral é presumido, em razão da medida abusiva da operadora de plano de saúde que poderia agravar a situação física e psicológica do beneficiário que já lutava contra uma doença grave e com poucas chances de recuperação, se agarrando ao tratamento medicamentoso que estava

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

fazendo e que havia chances de melhora, o qual foi interrompido indevidamente pela requerida.

Com efeito, é presumida a angústia e a dor do paciente que, mesmo pagando um alto custo mensal de plano de saúde, e se fiando na cobertura, depara-se com a recusa no momento em que mais precisa, ou seja, em contexto de pura vulnerabilidade.

Logo, a indenização por danos morais é medida de rigor.

No tocante ao valor a ser arbitrado a este título, como cediço, deve-se conjugar a moderação e a razoabilidade, significa dizer que são consideradas as condições econômicas das partes e as peculiaridades do caso em análise, de modo que acarrete o enriquecimento do ofendido, mas também sirva como um desestímulo ao ofensor na repetição do ato causador do dano.

Ademais, a reparação, por certo, não visa apenas mitigar os efeitos dos sentimentos negativos sofridos pela vítima, mas também inibir a reiteração da conduta ilícita perpetrada.

Assim, consideradas todas as circunstâncias do caso em concreto, o valor dos danos morais deve ser fixado em **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, importância esta que atende de forma satisfatória os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de relação contratual, como no presente caso, a fluência dos juros de mora de 1% ao mês incidentes sobre a condenação em indenização por danos morais se inicia na data da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

Por sua vez, a correção monetária deve ser feita pelo índice IGP-M/FGV, com incidência a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362, STJ.

Dispositivo

Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma prevista no artigo 487, I, do CPC, **julgo procedentes** os pedidos formulados nestes autos em que contende **Espólio de José Cícero de Oliveira**, representado por sua inventariante Gabrielle Rodrigues de Oliveira em face de **Unimed – Campo Grande MS – Cooperativa de Trabalho Médico**, para o fim de:

A) **condenar** a requerida na **obrigação de fazer,** consistente ao fornecimento do tratamento medicamentoso ao autor com o fármaco Erbitux na forma prescrita pelo médico que o acompanhava até o falecimento do paciente que ocorreu em 23/12/2021, confirmando-se a tutela deferida na decisão de f. 78-83, tornando-a definitiva;

B) **condenar** a requerida ao pagamento de indenização por **danos morais** no valor arbitrado em **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IGP-M/FGv, a partir do arbitramento.

C) **condenar** a requerida ao pagamento integral das custas processuais

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, o que faço com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, com as cautelas de estilo, em nada sendo requerido, arquivem-se, dando-se baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Grande-MS, *data da assinatura digital*.

Vania de Paula Arantes
Juiz(a) de Direito

Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/12/2022 às 15:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828068-79.2021.8.12.0001 e código Z6Qp7o5o.